

1525431-93.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1525431-93.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525431-93.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2308707/2019 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 8149794 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

3589/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2308707 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO,

3589/19/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO DI CARLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

FERNANDO DI CARLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, II, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Ele teria, no dia 22 de outubro de 2019, na Rua da Lagoa Danta, 92, Ermelino Matarazzo, nesta Capital, prevalecendo-se da função pública, guardado e mantido em depósito, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), 05 frascos contendo 4 mililitros de Tricloroetileno, 07 (sete) "eppendorfs" contendo cocaína, 3 (três) porções contendo 6,9g de Tetraidrocanabinol, popularmente conhecida como "maconha", 4 invólucros plásticos contendo 2,0g de cocaína na forma de "crack", 07 microtubos contendo 0,7g de

cocaína na forma "crack" e 03 invólucros de plástico contendo 1,2g de cocaína na forma de "crack".

Teria também, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, transportado uma munição de calibre 28, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, o réu (fls. 123) apresentou a defesa prévia (fls. 126/134), acompanhada dos documentos de fls. 135/215).

Considerando que o acusado também está respondendo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, foi adotado o rito ordinário no processamento do feito, recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, bem como determinada a citação e intimação do réu fls. (220/221).

O réu foi citado em audiência, fl. 402.

Durante a instrução da causa, foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postulou, oralmente, pela procedência da ação, nos termos da denúncia, com atenção à condição do acusado, que é policial militar, que deverá ser observada na dosimetria da pena. Na terceira fase, a exasperação da reprimenda, nos termos do artigo 40, inciso II, da Lei de Drogas, com início do cumprimento no regime fechado e perdimento da função pública. O Defensor constituído, por seu turno, postula preliminarmente pela nulidade da busca e apreensão veicular. No mérito, a improcedência da ação, e consequente absolvição do acusado. No caso de condenação, a desclassificação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para o artigo 28 da mesma lei e o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto a munição apreendida e por fim a revogação da medida cautelar de suspensão da atividade pública como Policial Militar.

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 7/9); o boletim de ocorrência (fls. 10/17); o auto de exibição e apreensão (fls. 18/19); o laudo de constatação preliminar (fls. 27/31); o mandado de prisão (fl. 34), de busca e apreensão (fl. 35), auto circunstanciado de busca e apreensão veicular (fls. 36/40), referentes ao Processo Militar nº 0001633-71.2017.8.26.0010; Folhas de antecedentes (fls. 54/55 e 84/85) e certidões cartorárias (fls. 56/57, 82/83 e 86) do acusado; bem como os laudos toxicológico definitivo (fls. 108/111), pericial do veículo (fls. 367/371); da munição (fls. 388/389) e da bolsa (fls. 390/393).

É o relatório.

Decido.

Quanto a preliminar de nulidade da busca e apreensão veicular, afasto-a.

No que tange a busca veicular, o patrono acusado se insurgiu sob argumento de que tal conduta policial foi além da ordem judicial, na qual não continha permissão para que o veículo fosse revistado. Pesem os argumentos defensivos, não houve qualquer ilegalidade na conduta dos policiais. Em primeiro lugar, o tráfico de entorpecente é crime permanente. Tratando-se de crime permanente, mostra-se prescindível, inclusive, o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. Portanto não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais, no sentido de proceder a busca veicular, teve como elementos precursores a ordem emanada pela Justiça Militar do Estado de São Paulo para apreender objetos de interesse à investigação policial-militar, para o fim de colher elementos de convicção com relação aos fatos lá discutidos na residência do acusado, esta precedida de mandado de busca judicial.

Assim, evidentemente não há sentido algum em se permitir a busca domiciliar, asilo inviolável com apenas as exceções constitucionais, e se reconhecer a ilegalidade da busca veicular do veículo que estava na posse do acusado. Nessa linha, não há que se falar em ilicitude ou ilegalidade da prova produzida.

Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial, conforme a seguir colaciono:

"HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida Preliminar - Violação de Domicílio -NÃO VERIFICADO - Presente in casu a justa causa para a adoção da medida de busca e

apreensão pelos policiais sem mandado judicial. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. Precedente do STF." No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP IMPOSSIBILIDADE A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanesçam os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2140716-14.2021.8.26.0000; Relator(a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Datado Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021).

Daí porque afasto essa alegação.

No mérito, a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o réu praticou tão somente o crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, eis que afastada a tipicidade da conduta de posse ilegal de munição de calibre permitido imputada ao agente, conforme adiante se verá.

A materialidade do tráfico é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 10/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação (fls. 27/31), e pelo toxicológico definitivo de fls. 108/111, que restou positivo em relação aos entorpecentes Tricloroetileno, cocaína e tetra-hidrocanabinol (THC), bem como as demais provas produzidas nos autos.

A autoria também não se discute, ante ao auto de prisão em flagrante delito (fls. 07/09) e à toda a prova oral colhida nos autos.

O policial militar responsável pela ocorrência, Murilo Bottrura Parras, quando ouvido em juízo, compromissado, declarou que conheceu o acusado no dia da busca domiciliar realizada. Havia um Inquérito Policial Militar instaurado contra o acusado de onde vários policiais estavam sendo investigados. Quando o mandado de busca é expedido pela Justiça Militar, um oficial tem que acompanhar. Nessa busca, pelo que se recorda, o réu franqueou a entrada sem problemas. A busca transcorreu normalmente, mas quando foi fazer a busca do veículo dele que estava do lado de fora da casa, encontrou uma valise com documentos, munições e entorpecentes. Os entorpecentes eram variados, um pouco de cada e já fracionados para venda. Lavrou-se o auto de busca domiciliar e veicular. Ele, indagado, disse que, caso fosse necessário, essa droga seria colocada em alguma ocorrência. Não sabe se o acusado é usuário de entorpecente. Não se recorda o tipo de munição nem o calibre. Ele não disse o que faria com as munições. Ele não disse que a droga teria sido apreendida em alguma ocorrência e que seria entregue a Delegacia de Polícia. Não se recorda se o mandado de busca domiciliar fazia menção a busca veicular.

Corroborando tal fala está o depoimento da segunda testemunha arrolada pela acusação, sargento José Calixto da Silva Júnior, que reconheceu o réu de uma operação da qual participou alguns anos atrás. A operação veio pela Corregedoria a qual cumpriu um mandado de busca na residência do policial, no caso o réu. Não participou da investigação deste inquérito, não sabe o teor. No dia dos fatos, foi feita uma busca na casa do policial e nada foi encontrado, mas no veículo que era do policial, o qual ele disse que era dele, um sedã pequeno, acabou encontrando uma mochila e no interior, vários tipos de entorpecentes e munição, mas não lembra o calibre e a quantidade. Indagado pelo tenente Parras, ele disse que usaria essa droga em outras ocorrências. Não o conhecia antes dos fatos. Não se recorda o objeto da busca. Na residência nada foi localizado. Não lembra se o mandado de busca incluía a busca veicular. Não se recorda se havia embalagens vazias.

Consolidada, a meu ver, a pratica ilícita decorrente dos escorreitos depoimentos policiais.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP - AC - Rel. Carlos Bueno - RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

O réu Fernando di Carlos, por sua vez, quando ouvido sob o crivo contraditório e da ampla defesa, negou os fatos. Declarou que é policial militar há 26 anos.

Divorciado, tem três filhos. Reconhece que o entorpecente foi localizado no veículo. Encontrou o entorpecente em um saco, isso na sexta feira. O encontro do entorpecente pelos policiais no cumprimento da ordem ocorreu na segunda feira. No dia dos fatos declarou que iria usar a droga em outras ocorrências porque não queria admitir perante a esposa que era usuário de drogas. Não conseguiu a droga através de seu trabalho policial. Estava sendo perseguido pela PM e por isso pretendia usar drogas. A versão apresentada pelo interrogando na delegacia é mentirosa. A mesma versão apresentou na Corregedoria da PM e lá, após varias investigações, concluíram que essa droga nunca teve origem em ocorrências policiais nas quais participou o interrogando. Só usava lança perfumes porque estava sendo perseguida pela PM. Não usava outros tipos de entorpecentes. Quanto aos outros tipos de drogas encontradas, afirmou pretendia usá-las futuramente. Nunca usou crack. A munição foi encontrada no mato, na praça próxima de casa, calibre 28. Pensou que fosse um chaveiro. A investigação que gerou o mandado foi em razão de quebra de sigilo funcional porque raquearam sua senha. Tudo para investigações de bingo. Foi absolvido em tudo.

Sua versão exculpatória, no entanto, não merece prosperar. Difícil crer na versão apresentada pelo réu em juízo, na medida em que as versões apresentadas por ele extrajudicialmente aos policiais no momento da sua prisão, a apresentada em solo policial e a apresentada em juízo são totalmente desconexas. Não faz sentido algum um policial, com 26 (vinte e seis) anos de carreira, manter em depósito drogas que afirma não usar, inclusive crack, para que futuramente pudesse vir a fazer uso desses entorpecentes. Mais absurdo ainda é confundir uma munição de arma de fogo, ferramenta da qual faz uso diariamente por conta do seu ofício, com um chaveiro. A versão é fantasiosa, estapafúrdia e pueril, desprovida de qualquer credibilidade. Extrapola completamente o bom senso.

Já a prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e seqüenciais, além de trazer muitos detalhes a respeito dos fatos ora apurados, ao contrário da versão, na verdade versões, apresentadas pelo acusado que são contraditórias em todos os sentidos. Com efeito, os milicianos foram firmes ao narrar a maneira como se deu a abordagem do acusado, bem como onde teria sido encontrada e acondicionada as drogas encontradas no interior do veículo, restando clara a prática do tráfico de entorpecentes.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se ao nefasto tráfico, tendo em mente que o acusado mantinha no interior do seu automóvel 05 frascos contendo 4 mililitros de Tricloroetileno, 07 (sete) “eppendorfs” contendo cocaína, 3 (três) porções contendo 6,9g de

Tetraidrocanabinol, popularmente conhecida como "maconha", 4 invólucros plásticos contendo 2,0g de cocaína na forma de crack", 07 microtubos contendo 0,7g de cocaína na forma "crack" e 03 invólucros de plástico contendo 1,2g de cocaína na forma de "crack", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 27/31 e laudo toxicológico definitivo de fls. 108/111. A maneira que estavam acondicionadas, já individualizadas em porções, acrescida às declarações dos policiais e às declarações fantasiosas do réu, denunciam o referido comércio. Nesse sentido, é bom lembrar que:

"A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio" (TACRIM-SP - AC 223.693 - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 63/240).

Quanto à munição encontradas na ocasião, esta foi periciada (fls. 388/389), restando livre de dúvida seu potencial ofensivo.

Com o réu foi apreendida somente uma munição de calibre nominal 28.

Todavia, quanto a este ponto específico, destaco que o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionálíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munição, desde que desacompanhadas da arma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. QUANTIDADE APREENDIDA: 1 CARTUCHO CALIBRE .40. AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO. INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto pelas instâncias ordinárias a munição de calibre restrito foi encontrada no quarto do denunciado, no guarda-roupas, dentro de uma gaveta. 2. A apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a preservação do decidido pela instância ordinária. 3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio (Resp n. 1.699.710/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017; e HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/5/2018). 4. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1856980 - SC (2020/0006029-0) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE SIGNIFICADO LESIVO.

1. Os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são crimes formais, de mera conduta e de perigo abstrato e se consumam independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, sendo o dano presumido pelo tipo penal. Assim, como regra geral, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição, notadamente porque não se cuidam de delitos desprovidos de periculosidade social em face mesmo da natureza dos bens jurídicos tutelados e do princípio da proteção eficiente.

2. Não obstante, inexistente perigo de lesão ou probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma na conduta de alguém que é ourives e vive de sua profissão comercializando jóias, sem qualquer notícia de envolvimento com práticas criminosas, em que foram apreendidas apenas três munições dentro da gaveta de uma mesa no interior do seu estabelecimento comercial, desacompanhadas de arma de fogo.

3. Recurso ministerial improvido. (Resp n. 1.699.710/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017 - grifo nosso).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EVIDENCIADA. DUAS MUNIÇÕES APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DE DISPARO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017). 6. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia, em razão da atipicidade material da conduta imputada ao agente. (HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 30/05/2018).

Assim sendo, a apreensão de ínfima quantidade de munição, no caso uma, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a improcedência da ação em relação ao crime de posse ilegal de munição de calibre permitido, em razão da atipicidade da conduta imputada ao agente.

Assim, diante de tais elementos de convicção, não restam dúvidas de que o proceder do réu se amolda perfeitamente somente ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo a sua condenação medida necessária, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Quanto a aplicação do artigo 40 II da Lei de Drogas, afasto sua incidência na medida em que não há provas de que o acusado praticou o crime prevalecendo-se de sua função. Com efeito, o entorpecente foi localizado no interior de seu veículo particular e não há provas de que ele se prevaleceu pelo fato de ser policial militar. Entendo que o no caso concreto, o que deve incidir é a agravante prevista pelo artigo 61, I, alínea "g" do Código Penal porque agindo da forma como agiu, violou dever inerente ao cargo, ou seja, estrito respeito a legislação pátria, principalmente a legislação penal.

Passo a dosar as penas.

O acusado é primário e de bons antecedentes, conforme se verifica da F.A de fls. 84/85 e certidão de fls. 86.

Fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os entorpecentes apreendidos em posse dele, bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente ocorre. Nada a justificar, a meu sentir, o aumento da básica por este fator.

Em segunda fase, reconheço a agravante de violação de dever inerente ao cargo, nos termos do artigo 61, inciso I, alínea "g", do Código Penal, motivo pelo qual aumento-lhe a pena em 1/6 (um sexto) e chego em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui Maus antecedentes. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrassem organização criminosa apenas porque ele e estivessem na posse de 4 (quatro) mililitros de Tricloroetileno e 5,9g (cinco gramas e nove miligramas) de entorpecentes, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de Maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente

comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3. Assim sendo, diminui a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 1.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevantes o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Efeitos secundários da sentença penal condenatória - artigo 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal.

Observo, primeiramente, o delito foi praticado por servidor público, integrante dos Quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem como munus publico justamente a prevenção e repressão ao crime.

Com efeito, conforme comprovado durante a instrução, restou demonstrada a grave violação ao dever funcional do acusado, violando, assim, os deveres para com a Administração Pública.

Sabe-se que a moralidade é um dos princípios norteadores da Administração Pública, dever de conduta geral para todo e qualquer servidor, em todas as esferas dos Três Poderes. No entanto, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes violou, sobremaneira, o dever profissional do réu.

Ora, o acusado é policial militar e, embora não estivesse no exercício de sua função, violou dever inerente as suas funções como policial, bem como para com a administração pública, considerando seu vínculo a esta no exercício de suas atividades diárias.

Caracterizada, portanto, infração gravíssima em face da administração pública, notadamente pela sua função precípua de reprimir a prática delitiva.

Segundo BITENCOURT¹, em seu Código Penal Comentado, para a perda do cargo ou função pública, são necessários os seguintes requisitos: (i) pena aplicada superior ou igual a um ano de prisão; (ii) abuso de poder ou violação de dever para com a

Administração Pública; (iii) fundamentação na sentença condenatória.

Diante do exposto, como efeito específico da condenação, declaro a perda do cargo ou função pública do réu, com fundamento no art. 92, inciso. I, parágrafo único, do Código Penal, por decorrência da presente condenação, tendo em vista que a pena restou superior a um ano de reclusão e o réu agiu com elevada quebra de sua capacidade moral de continuar no trabalho, demonstrando ausência de senso ético, pessoa remunerada pelos cofres públicos do Estado para combater o crime.

Assim sendo, imponho, como efeito secundário da condenação penal a sanção da perda do cargo e função exercida à época pelo acusado.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e CONDENO FERNANDO DI CARLO, qualificado nos autos, como incursos nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, piso mínimo, e corrigidos desde a data do fato, ABSOLVO-O da acusação prevista pelo artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Por fim, imponho como efeito secundário da condenação penal a sanção da perda do cargo e função exercida pelo acusado.

Concedo o apelo em liberdade.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que, na condição de policial militar da ativa, claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, drogas estas capazes de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

Isento de custas.

P.R.I.C

São Paulo, 03 de junho de 2021.